APELAÇÃO CÍVEL Nº 5033029-55.2015.4.04.9999/PR

RELATOR	:	**PAULO AFONSO BRUM VAZ**
APELANTE	:	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
APELADO	:	**WELLINGTON FELIPE ARIGONI DORTA**
ADVOGADO	:	**DORISVALDO NOVAES CORREIA**

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. **BENEFÍCIO ASSISTENCIAL**. REQUISITOS. **MENOR** DE IDADE. POSSIBILIDADE.

1. O direito ao **benefício assistencial** pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: a) **condição de deficiente** (*incapacidade para o trabalho e para a vida independente*, de acordo com a redação original do art. 20 da LOAS, ou *impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas,* conforme redação atual do referido dispositivo) ou **idoso** (neste caso, considerando-se, desde 1º de janeiro de 2004, a idade de 65 anos); e b) **situação de risco social** (estado de miserabilidade, hipossuficiência econômica ou situação de desamparo) da parte autora e de sua família.

2. Inexiste impedimento à concessão do **benefício assistencial** de prestação continuada a **menor** de idade. Precedentes da Corte.

3. Atendidos os pressupostos, deve ser concedido o benefício.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Colenda 5a. Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, **negar provimento à apelação, dar parcial provimento à remessa oficial e determinar a implantação imediata do benefício**, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 01 de dezembro de 2015.

Desembargador Federal PAULO AFONSO BRUM VAZ
Relator

Documento eletrônico assinado por **Desembargador Federal PAULO AFONSO BRUM VAZ, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7949228v3** e, se solicitado, do código CRC **FE663932**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Paulo Afonso Brum Vaz
Data e Hora: 02/12/2015 15:54

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5033029-55.2015.4.04.9999/PR

RELATOR	:	**PAULO AFONSO BRUM VAZ**
APELANTE	:	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
APELADO	:	**WELLINGTON FELIPE ARIGONI DORTA**
ADVOGADO	:	**DORISVALDO NOVAES CORREIA**

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo INSS em face da sentença que julgou **procedente** o pedido de concessão de ***benefício assistencial*** *devido à pessoa com deficiência*.

Sustenta, em síntese, que a parte autora não preenche os requisitos necessários, pois a renda *per capita* familiar supera ¼ do salário mínimo.

Com as contrarrazões, e por força do reexame necessário, subiram os autos a esta Corte para julgamento.

A Procuradoria Regional da República da 4ª Região opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Premissas

Trata-se de demanda previdenciária na qual a parte autora objetiva a concessão de **BENEFÍCIO ASSISTENCIAL**, previsto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal e regulamentado pelo artigo 20 da Lei nº 8.742/93, com a redação dada pelas Leis nº 12.435, de 06-07-2011, e nº 12.470, de 31-08-2011.

O direito ao **benefício assistencial** pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: a) **condição de deficiente** (*incapacidade para o trabalho e para a vida independente*, de acordo com a redação original do art. 20 da LOAS, ou *impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas,* conforme redação atual do referido dispositivo) ou **idoso** (neste caso, considerando-se, desde 1º de janeiro de 2004, a idade de 65 anos); e b)

situação de risco social (estado de miserabilidade, hipossuficiência econômica ou situação de desamparo) da parte autora e de sua família.

Saliente-se, por oportuno, que a incapacidade para a vida independente a que se refere a Lei 8.742/93, na redação original, deve ser interpretada de forma a garantir o **benefício assistencial** a uma maior gama possível de *pessoas com deficiência*, consoante pacífica jurisprudência do STJ (*v.g.* STJ, 5ª Turma, RESP 360.202/AL, Rel. Min. Gilson Dipp, DJU de 01-07-2002) e desta Corte (*v.g.* AC n. 2002.71.04.000395-5/RS, 6ª Turma, Rel. Des. Federal João Batista Pinto Silveira, DJU de 19-04-2006).

Desse modo, a incapacidade para a vida independente (a) não exige que a pessoa possua uma vida vegetativa ou seja incapaz de se locomover; (b) não significa incapacidade para as atividades básicas do ser humano, tais como alimentar-se, fazer a higiene pessoal e vestir-se sozinho; (c) não impõe a incapacidade de se expressar ou se comunicar; e (d) não pressupõe dependência total de terceiros.

No que diz respeito ao requisito econômico, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça admitiu, em sede de *Recurso Repetitivo*, a possibilidade de demonstração da condição de miserabilidade por *outros meios de prova*, quando a renda *per capita* familiar fosse superior a ¼ do salário mínimo (REsp 1112557/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 20/11/2009). Posteriormente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 18-04-2013, a Reclamação nº 4374 e o Recurso Extraordinário nº 567985, este com *repercussão geral*, reconheceu e declarou, *incidenter tantum*, a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei 8.742/93 (LOAS), por considerar que o critério ali previsto - ser a renda familiar mensal *per capita* inferior a um quarto do salário mínimo - está defasado para caracterizar a situação de miserabilidade.

Assim, forçoso reconhecer que as despesas com os cuidados necessários da parte autora, especialmente medicamentos, alimentação especial, fraldas descartáveis, tratamento médico, psicológico e fisioterápico, podem ser levadas em consideração na análise da condição de miserabilidade da família da parte demandante.

A propósito, a eventual percepção de recursos do Programa Bolsa Família, que, segundo consta no site do Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome (http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/), destina-se à *"transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País*" e "*tem como foco de atuação os 16 milhões de brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$ 70,00 mensais, e está baseado na garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos*", não só não impede a percepção do **benefício assistencial** do art. 203, V, da Constituição Federal, como constitui prova indiciária acima de qualquer dúvida razoável de que a unidade familiar se encontra em situação de grave risco social.

Registre-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 580.963/PR, realizado em 17-04-2013, declarou, outrossim, a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), o qual estabelece que o **benefício assistencial** já concedido a qualquer idoso membro da família "*não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS*", baseado nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia, bem como no caráter de essencialidade de que se revestem os benefícios de valor mínimo,

tanto previdenciários quanto assistenciais, concedidos a pessoas idosas e também àquelas portadoras de deficiência. Segundo o STF, portanto, não se justifica que, para fins do cálculo da renda familiar per capita, haja previsão de exclusão apenas do valor referente ao recebimento de **benefício assistencial** por membro idoso da família, quando verbas de outra natureza (benefício previdenciário), bem como outros beneficiários de tais verbas (membro da família portador de deficiência), também deveriam ser contemplados.

Este TRF, aliás, já vinha julgando no sentido da desconsideração da interpretação restritiva do artigo 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso.

Assim, no cálculo da renda familiar *per capita*, deve ser excluído o valor auferido por idoso com 65 anos ou mais a título de **benefício assistencial** ou benefício previdenciário de renda mínima (EIAC nº 0006398-38.2010.404.9999/PR, julgado em 04-11-2010), ou de benefício previdenciário de valor superior ao mínimo, até o limite de um salário mínimo, bem como o valor auferido a título de benefício previdenciário por incapacidade ou assistencial em razão de deficiência, independentemente de idade (EIAC N.º 2004.04.01.017568-9/PR, Terceira Seção, julgado em 02-07-2009. Ressalto que tal pessoa, em decorrência da exclusão de sua renda, também não será considerada na composição familiar, para efeito do cálculo da renda *per capita*.

Exame do caso concreto

Em relação à alegada *incapacidade* da parte autora, constam do laudo médico, realizado por perito de confiança do juízo *a quo,* os seguintes dados (evento 47):

a- enfermidade (CID): F71 (retardo mental);
b- incapacidade: existente;
c- grau da incapacidade: total e permanente;
d- início incapacidade: desde o nascimento;
f- idade atual: 8 anos;
g- observações gerais: necessita de auxílio de terceiros para a realização das atividades da vida diária .

No tocante ao *requisito econômico*, foi elaborado parecer social, a partir de visita realizada em 05/11/2013, no qual se destacam os aspectos abaixo indicados (evento 21):

a - grupo familiar: quatro pessoas - o autor, sua mãe (Lucélia), sua avó e guardiã (Izabel) e seu tio (Vitor);
b - renda familiar: R$ 1.356,00, equivalentes a dois salários mínimos, advindos do benefício de pensão por morte percebido pela avó e do **benefício assistencial** percebido pela mãe do demandante;
c - condições de moradia: a casa é simples e de alvenaria, composta de quatro quartos, sala, cozinha e banheiro;
d - despesas com cuidados pessoais: o autor necessita de assistência médica constante, remédios e alimentação especial;
e - cadastro em programas públicos de assistência social: a mãe do demandante

recebe **benefício assistencial** por ser portadora de deficiência intelectual.

Conclusão quanto ao direito da parte autora no caso concreto

O exame do conjunto probatório demonstra que a parte autora possui incapacidade total e definitiva para reger a sua vida e seus bens, necessitando de cuidados permanentes para sobreviver com dignidade.

No que tange à situação de risco social, de acordo com o entendimento transcrito mais acima, a renda de um salário mínimo percebida pela mãe do autor, a título de **benefício assistencial**, deve ser excluída do cômputo da renda familiar. Com tal exclusão, a renda familiar estaria limitada a um salário mínimo, a qual, considerado o número de membros da família, resultaria em renda mensal *per capita* abaixo dos parâmetros adotados pelos Tribunais Superiores.

Portanto, deve ser reconhecido o direito do demandante ao **benefício assistencial** desde a data do requerimento administrativo (22/10/2012), não havendo parcelas prescritas, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 31/07/2013.

Por oportuno, cabe dizer que inexiste impedimento à concessão do **benefício assistencial** de prestação continuada a **menor** de idade. Ao contrário, a assistência social a crianças e adolescentes é prioritária em nosso País, à luz do art. 203, incisos I e II, da Constituição Federal. Se o **menor** é **deficiente**, a proteção social é reforçada, conforme os incisos IV e V do mesmo artigo. Em matéria de assistência social, à vista do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III), não é possível interpretação restritiva contrária aos que a Constituição e a lei manifestamente buscaram proteger. Nesse sentido: AC 0012344-15.2015.404.9999, Sexta Turma, Relator Des. Federal João Batista Pinto Silveira, D.E. 15/10/2015.

Dos consectários

Segundo o entendimento das Turmas previdenciárias do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, estes são os critérios aplicáveis aos consectários:

Correção monetária

Com base no posicionamento consolidado na 3ª Seção deste TRF4, a correção monetária incidirá a contar do vencimento de cada prestação e será calculada pelos índices oficiais e aceitos na jurisprudência, quais sejam:

- ORTN (10/64 a 02/86, Lei nº 4.257/64);
- OTN (03/86 a 01/89, Decreto-Lei nº 2.284/86);
- BTN (02/89 a 02/91, Lei nº 7.777/89);
- INPC (03/91 a 12/92, Lei nº 8.213/91);
- IRSM (01/93 a 02/94, Lei nº 8.542/92);
- URV (03 a 06/94, Lei nº 8.880/94);
- IPC-r (07/94 a 06/95, Lei nº 8.880/94);

- INPC (07/95 a 04/96, MP nº 1.053/95);
- IGP-DI (05/96 a 03/2006, art. 10 da Lei nº 9.711/98, combinado com o art. 20, §§5º e 6º, da Lei nº 8.880/94);
- INPC (de 04/2006 a 29/06/2009, conforme o art. 31 da Lei n.º 10.741/03, combinado com a Lei n.º 11.430/06, precedida da MP nº 316, de 11/08/2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei nº 8.213/91).
- TR (a partir de 30/06/2009, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009)

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, afastando a utilização da TR como fator de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, relativamente ao período entre a respectiva inscrição em precatório e o efetivo pagamento.

Em consequência dessa decisão, e tendo presente a sua *ratio*, a 3ª Seção desta Corte vinha adotando, para fins de atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, a sistemática anterior à Lei nº 11.960/2009, o que significava, nos termos da legislação então vigente, apurar-se a correção monetária segundo a variação do INPC, salvo no período subsequente à inscrição em precatório, quando se determinava a utilização do IPCA-E.

Entretanto, a questão da constitucionalidade do uso da TR como índice de atualização das condenações judiciais da Fazenda Pública, no período antes da inscrição do débito em precatório, teve sua repercussão geral reconhecida no RE 870.947, e aguarda pronunciamento do STF no que se refere ao mérito. A relevância e transcendência da matéria foram reconhecidas especialmente em razão das interpretações que vinham ocorrendo nas demais instâncias quanto à abrangência do julgamento nas ADIs 4.357 e 4.425.

Recentemente, em sucessivas reclamações, a Suprema Corte vem afirmando que, no julgamento das ADIs em referência, a questão constitucional decidida restringiu-se à inaplicabilidade da TR ao período de tramitação dos precatórios, de forma que a decisão de inconstitucionalidade por arrastamento foi limitada à pertinência lógica entre o art. 100, § 12, da CRFB e o artigo 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009. Em consequência, as reclamações vêm sendo acolhidas, assegurando-se que, ao menos até que haja decisão específica do STF, seja aplicada a legislação em referência na atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, salvo após inscrição em precatório. Os pronunciamentos sinalizam, inclusive, para eventual modulação de efeitos, acaso sobrevenha decisão mais ampla quanto à inconstitucionalidade do uso da TR para correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública (Rcl 19.050, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 21.147, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 19.095, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Em tais condições, com o objetivo de guardar coerência com os mais recentes posicionamentos do STF sobre o tema, e para prevenir a necessidade de futuro sobrestamento dos feitos apenas em razão dos consectários, a melhor solução a ser adotada, por ora, é aplicar o critério de atualização estabelecido no art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/2009, merecendo provimento a apelação do INSS quanto ao ponto.

Este entendimento não obsta que o juízo de execução observe, quando da liquidação e atualização das condenações impostas ao INSS, o que vier a ser decidido pelo STF em regime de repercussão geral, bem como eventual regramento de transição que

advenha em sede de modulação de efeitos.

Juros de mora

Até 29-06-2009, os juros de mora, apurados a contar da data da citação, devem ser fixados à taxa de 1% ao mês, com base no art. 3º do Decreto-Lei nº 2.322/87, aplicável analogicamente aos benefícios pagos com atraso, tendo em vista o seu caráter eminentemente alimentar, consoante firme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e na Súmula 75 desta Corte.

A partir de então, os juros incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo o índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança, nos termos estabelecidos no art. 1º-F, da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/2009. Os juros devem ser calculados sem capitalização, tendo em vista que o dispositivo determina que os índices devem ser aplicados *uma única vez* e porque a capitalização, no direito brasileiro, pressupõe expressa autorização legal (STJ, 5ª Turma, AgRg 1211604/SP, Rel. Min. Laurita Vaz).

Quanto ao ponto, esta Corte já vinha entendendo que, no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, não houve pronunciamento de inconstitucionalidade sobre o critério de incidência dos juros de mora previsto na legislação em referência.

Esta interpretação foi, agora, chancelada, pois no exame do recurso extraordinário 870.947, o STF reconheceu repercussão geral, não apenas no que diz respeito à questão constitucional pertinente ao regime de atualização monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública, mas, também, à controvérsia relativa aos juros de mora incidentes.

Tendo havido a citação já sob a vigência das novas normas, inaplicáveis as disposições do Decreto-lei 2.322/87, incidindo apenas os juros da caderneta de poupança, sem capitalização.

Honorários Advocatícios

Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, excluídas as parcelas vincendas, observando-se a Súmula 76 desta Corte: "*Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, devem incidir somente sobre as parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforme a sentença de improcedência*".

Custas Processuais

O INSS é isento do pagamento das custas no Foro Federal (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96) e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, devendo, contudo, pagar eventuais despesas processuais, como as relacionadas a correio, publicação de editais e condução de oficiais de justiça (artigo 11 da Lei Estadual nº 8.121/85, com a redação da Lei Estadual nº 13.471/2010, já considerada a inconstitucionalidade formal reconhecida na ADI nº 70038755864 julgada pelo Órgão Especial do TJ/RS), isenções estas que não se aplicam

quando demandado na Justiça Estadual do Paraná (Súmula 20 do TRF4), devendo ser ressalvado, ainda, que, no Estado de Santa Catarina (art. 33, par. único, da Lei Complementar estadual 156/97), a autarquia responde pela metade do valor.

Implantação do benefício

Reconhecido o direito da parte, impõe-se a determinação para a imediata implantação do benefício, nos termos do art. 461 do CPC (TRF4, Terceira Seção, QO-AC nº 2002.71.00.050349-7, Rel. p/ acórdão Des. Federal Celso Kipper).

Por oportuno, vale ressaltar que não se cogita de ofensa aos artigos 128 e 475-O, I, do CPC, porque a hipótese, nos termos do precedente da 3ª Seção, não é de antecipação, de ofício, de atos executórios. A implantação do benefício decorre da natureza da tutela judicial deferida.

Dessa forma, em vista da procedência do pedido e do que estabelecem os artigos 461 e 475-I, *caput*, bem como dos fundamentos expostos no precedente referido alhures, e inexistindo embargos infringentes, deve o INSS implantar o benefício em até 45 dias, conforme os parâmetros acima definidos, incumbindo ao representante judicial da autarquia que for intimado dar ciência à autoridade administrativa competente e tomar as demais providências necessárias ao cumprimento da tutela específica, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Conclusão

Reforma-se a sentença apenas para adequar os consectários.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação, dar parcial provimento à remessa oficial e determinar a implantação imediata do benefício.

Desembargador Federal PAULO AFONSO BRUM VAZ
Relator

Documento eletrônico assinado por **Desembargador Federal PAULO AFONSO BRUM VAZ, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7949227v4** e, se solicitado, do código CRC **F223AB12**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): Paulo Afonso Brum Vaz

Data e Hora: 02/12/2015 15:54

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 01/12/2015

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5033029-55.2015.4.04.9999/PR
ORIGEM: PR 00009338720138160133

RELATOR	:	Des. Federal PAULO AFONSO BRUM VAZ
PRESIDENTE	:	Paulo Afonso Brum Vaz
PROCURADOR	:	Dr. Jorge Luiz Gasparini da Silva
APELANTE	:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO	:	WELLINGTON FELIPE ARIGONI DORTA
ADVOGADO	:	DORISVALDO NOVAES CORREIA

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 01/12/2015, na seqüência 166, disponibilizada no DE de 18/11/2015, da qual foi intimado(a) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.

Certifico que o(a) 5ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL E DETERMINAR A IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

RELATOR ACÓRDÃO	:	Des. Federal PAULO AFONSO BRUM VAZ
VOTANTE(S)	:	Des. Federal PAULO AFONSO BRUM VAZ
	:	Des. Federal ROGERIO FAVRETO
	:	Juiz Federal LUIZ ANTONIO BONAT

Lídice Peña Thomaz
Secretária de Turma

Documento eletrônico assinado por **Lídice Peña Thomaz, Secretária de Turma**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **8017719v1** e, se solicitado, do código CRC **BED32A15**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Lídice Peña Thomaz
Data e Hora:	02/12/2015 11:35